

1501503-65.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... restritiva de direito em hipótese de crime de tráfico, nesse rumo, confirmam-se os seguintes precedentes:

"TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 72,2 gramas de maconha e 6,4 gramas de crack. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão parcial em juízo, assumindo a posse de apenas parte do entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501503-65.2021.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501503-65.2021.8.26.0286

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307373/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21330923 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3162/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2307373 - DEL.POL.SALTO, 3162/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANA CRISTINA MARCHESIM AGUIAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra a ré JULIANA CRISTINA MARCHESIM AGUIAR, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Emílio Ribas, nº 1, Vila Flora, nesta cidade e Comarca de Salto/SP, a acusada, em ocasião de calamidade pública, vendeu a Juliano Rodrigues Costa Pinto, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 04 (quatro) porção de "crack", com peso líquido de 0,46g (quarenta e seis centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 66-70).

A ré foi notificada pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 89-92).

A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (fl. 98-99).

Durante a instrução processual foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação pela defesa, 03 (três) testemunhas comuns e a ré foi interrogada. Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-09), auto de exibição e apreensão (fl. 10), auto de constatação preliminar (fls. 11) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 57-59), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

A testemunha Juliano Rodrigues Costa, na fase policial, relatou que é usuária de crack. Foi até o local dos fatos comprar crack. Em um bar, informaram que Juliana vendia drogas. Pediu quatro pedras de crack e entregou a ela a importância de R\$ 40,00, duas notas de vinte. Não a conhecia. Havia outras pessoas junto de Juliana. Assim que apanhou as drogas e estava deixando o local, se deparou com uma viatura da GCM e foi abordado por eles. Confirmou aos GCMs que tinha comprado as drogas de Juliana.

Os guardas municipais, Ronaldo Siqueira de Melo e Claudemir Tenorio da Silva, testemunhas comuns, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam realizando patrulhamento, quando avistaram a ré e Juliano trocando algo entre eles. Ao notarem a aproximação da viatura os suspeitos se separaram. Foram abordados e em revista pessoal, na posse de Juliano foram localizadas 04 porções de crack, que alegou ter comprado a droga de Juliana. Pagou com duas notas de vinte reais. Com Juliana, foi encontrada a importância de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais). A ré negou ter vendido drogas a Juliano e que estava no local somente para intermediar a negociação. Não informou de quem adquiriu a droga.

A testemunha arrolada pela defesa Karolina Araujo dos Santos prestou depoimento abonatório da conduta da acusada mas nada esclareceu sobre os fatos.

A ré, Juliana Cristina Marchesim Aguiar, interrogada judicialmente, nega que estava vendendo drogas. Disse, em resumo, que é usuária.

Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que a ré guardava, trazia consigo e vendeu a Juliano Rodrigues Costa Pinto, 04 (quatro) porção de "crack", todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros, afastando-se, assim, a tese do consumo pessoal. No mesmo sentido o depoimento de Juliano Rodrigues Costa na fase inquisitiva, que pode ser valorado nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, em cotejo com a prova produzida na instrução processual.

O simples fato de a ré alegar ser usuária ou possuir outra fonte de renda lícita não a impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Em que pese a negativa de autoria pela acusada, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, haja vista que a acusada foi presa em flagrante após os

guardas presenciarem a negociação ilícita, confirmada por terceiro, Juliano Rodrigues Costa, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar a acusada.

As circunstâncias da prisão, a forma de armazenamento da droga apreendida, acompanhada de valor em dinheiro, tudo alinhado à versão do usuário e dos agentes policiais, denotam o intuito mercantil.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indiquem que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior tribunal de Justiça, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 04 (quatro) porção de "crack", com peso líquido de 0,46g (quarenta e seis centigramas), a ré é

primária (fls. 116) e não restou provado que integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de pena restritiva de direito em hipótese de crime de tráfico, nesse rumo, confirmam-se os seguintes precedentes:

"TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 72,2 gramas de maconha e 6,4 gramas de crack. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão parcial em juízo, assumindo a posse de apenas parte do entorpecente para consumo próprio. Negativa do tráfico isolada do conjunto probatório. Invocação da condição de mero usuário. Condenação fundada no depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da droga. Validade. Pretendida desclassificação para a figura do referido artigo 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Sinais indicativos do comércio ilegal. Não comprovação, ademais, de atividade lícita remunerada que lhe rendesse condições financeiras para sustentar o consumo. Condenação mantida. PENA. Acréscimo da pena-base justificado pela natureza do entorpecente e seu alto poder viciante. Retorno ao mínimo legal por conta da menoridade. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com seu redutor máximo. Admissibilidade. Requisitos legais atendidos. Pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Substituição do regime prisional fechado pelo aberto. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo provido para esses fins. (TJ-SP - APL: 00028796820118260624 SP 0002879-68.2011.8.26.0624, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 19/02/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2013)"

"O regime inicial fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a publicação da Lei nº

11.464, de 29 de março de 2007, que deu nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, ressaltando a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, quando, aplicada a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, for substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fim de adequar a reprimenda ao benefício concedido justamente para evitar o encarceramento. Precedentes do STF e do STJ"(HC nº 191.392/MT, 5ª Turma, Relatora Minª. Laurita Vaz, DJE 22.08.11, VU)".

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 44 DA LEI 11.343/2006:

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigura-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou derestrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamento do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. (...)"(HC nº 97.256/RS, Pleno, julgado em 1º.09.2010, M.V.)". Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a ré é tecnicamente primária (Art. 76 § 4º da Lei 9099/1995), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização

criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR a ré JULIANA CRISTINA MARCHESIM AGUIAR, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará a réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA